

1500293-24.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... lugar conhecido pela prática de tráfico. Esclareceu que visualizaram o veículo do réu trafegando em alta velocidade na pista contrária a que estavam, tratando-se de veículo com insuflado e que isso era em horário muito cedo. Afirmou que o réu, de imediato, confessou o tráfico, reiterando que o acusado disse que estaria levando o entorpecente para a "linha do trem", na cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijó - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjsp.jus.br

1500293-24.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500293-24.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSCAR LIMA DOS SANTOS

CONCLUSÃO: Em 20/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de OSCAR LIMA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, constando da denúncia que, no dia 05 de abril de 2022, por volta de 08h30min, na Rodovia Raposo Tavares - SP 270, sentido capital/interior, na altura do Km 553, nesta cidade e comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado às fls. 08/09, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 1,055 Kg de cocaína na forma de crack, acondicionada em 01 tijolo (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de pericial de fls. 97/99).

Citado (fl. 141), o réu, através de defensora constituída (fl. 51), apresentou resposta à acusação (fls. 125/137).

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022 (fls. 147/153).

Durante a instrução, houve a colheita da prova testemunhal, tendo o réu sido interrogado. Na sequência, o Ministério Público apresentou alegações finais de maneira oral (fl. 227).

Alegações finais do réu às fls. 230/255.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 19), pelas fotografias de fls. 20/21, pelo auto de constatação preliminar (fls. 26/27), pelo laudo pericial de fls. 97/99, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A testemunha de acusação Fernando Capelasso Bolqui, policial militar, aduziu que estavam em patrulhamento pela rodovia Raposo Tavares, quando foi avistado um veículo Palio Weekend no contrafluxo, tendo sido despertada forte suspeita da equipe policial, de modo que passou-se a acompanhá-lo. Narrou que foi dado sinal de parada e que, durante a abordagem, o réu informou que era morador de Presidente Prudente e que estava vindo da casa de familiares, residentes cidade de Anhumas. Que, então, despertou-se suspeita, tratando-se de por volta das 08h da manhã.

Relatou que foi solicitado que o acusado desembarcasse do veículo para realização de busca minuciosa no automóvel. Consignou que quando o réu desceu do veículo, de imediato, foi notado volume na altura da cintura do acusado. Indagado o acusado acerca do referido volume, ele levantou a camiseta e imediatamente foi constatado que se tratava de por volta de 1 Kg de tijolo de crack. Que, então, foi dada voz de prisão ao acusado. Questionado o réu acerca do entorpecente, esse afirmou que o havia pegado perto de uma placa de sinalização [de trânsito], próxima à cidade de Anhumas e que o estaria levando para a "linha do trem", local situado na cidade de Presidente Prudente, lugar conhecido pela prática de tráfico. Esclareceu que visualizaram o veículo do réu trafegando em alta velocidade na pista contrária a que estavam, tratando-se de veículo com insulfilm e que isso era em horário muito cedo. Afirmou que o réu, de imediato, confessou o tráfico, reiterando que o acusado disse que estaria levando o entorpecente para a "linha do trem", na cidade de Presidente Prudente. Declarou que não conheciam o réu. Detalhou que inicialmente o veículo do acusado foi avistado em vicinal de acesso à Rodovia Raposo Tavares e que, quando retornaram para abordá-lo, este já estava na referida Rodovia. Não soube precisar o tempo decorrido entre a primeira visualização do veículo do réu e a abordagem. Esclareceu que a ordem de parada consistiu em terem dado sinais sonoros e luminosos e que, de pronto, o réu obedeceu. Mencionou que o réu se comportava normalmente, acreditando que o acusado tenha colocado a droga no corpo antes de ser abordado, não a tendo no corpo o "tempo inteiro". Confirmou que vistoriou o automóvel, no qual não foi percebido compartimento "falso ou secreto". Afirmou que o réu não tinha aparelho celular no momento dos fatos, ressaltando que o acusado informou que havia esquecido o celular em casa. Elucidou que não foi percebida a presença de rádio HT, mapa no veículo. Disse que se o réu seguisse o trajeto que desempenhava, sem desviar, passaria pela base da polícia rodoviária da cidade de Presidente Prudente. Consignou que não foi notada a presença de "batedor" acompanhando o veículo do réu. Reiterou que o automóvel conduzido pelo réu era uma Palio Weekend, tratando-se de veículo velho. Disse que o réu em nenhum momento tentou empreender fuga, tendo obedecido a todas as ordens.

A testemunha de acusação Fabio Soares Dias, policial militar rodoviário, declarou que estavam em patrulhamento pela rodovia Raposo Tavares, quando nas proximidades do Km 553, foi visualizado um veículo Palio Weekend com a suspensão traseira bastante erguida, o que é comum em carros utilizados para a prática de tráfico ou de descaminho. Que, então, resolveram abordar o veículo, sendo que o réu, proprietário do automóvel, era quem o conduzia. Relatou que a abordagem no mencionado, na referida rodovia, se deu por volta das 08h30min. Detalhou que o réu foi indagado acerca de onde estava vindo, tendo ele informado que estava vindo da cidade de Anhumas, sem, porém, explicar o motivo da ida até a referida cidade. Que vistoriado o veículo, nada de ilícito foi encontrado. Que ao ser realizada a busca

peçoal no réu, na altura da cintura foi localizado um tablete de crack. Mencionou que perguntou ao acusado a destinação do entorpecente, tendo o réu inicialmente respondido que iria vender a droga na cidade de Presidente Prudente. Aduziu que o acusado declarou que havia pegado a droga perto de uma placa de sinalização [de trânsito], na vicinal de acesso à cidade de Anhumas. Que, então, foi dada voz de prisão e o acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia de Regente Feijó. Asseverou que, na Delegacia, o réu apresentou outra versão acerca do entorpecente, narrando ser usuário de cocaína e que estava em dívida com traficante da cidade de Presidente Prudente e que, para obter o perdão da dívida de R\$ 800,00, foi até próximo à cidade de Anhumas, pegou o tablete de entorpecente e o levaria até o traficante e, com isso, teria o perdão da dívida. Confirmou que o réu, na Delegacia, apresentou a versão de que não iria consumir o entorpecente, mas que o estava transportando para pagamento de dívida de droga. Ressaltou que com o réu foram encontrados R\$ 112,00 e que ele não estava com aparelho celular, estando em nome do acusado o veículo abordado e que conduzia. Negou que conhecia o réu dos meios policiais. Informou ter sido pesquisado “os antecedentes criminais” do réu, não se tendo igualmente obtido informação do réu em relação aos meios policiais. Não se recorda se o réu tinha passagem pela Polícia. Confirmou que a primeira visualização do veículo do réu foi na via vicinal de acesso Rodovia Raposo Tavares - cidade de Anhumas, tendo a abordagem se dado no Km 553, da referida rodovia. Disse que a todo momento tinham a visualização sobre o veículo e que foi dado sinal de parada o que foi obedecido prontamente. Não soube precisar por quanto tempo e distância ficaram no encalço do réu até haver a abordagem. Esclareceu que a ordem de parada consistiu em terem dado sinais sonoros e luminosos. Declarou que o réu não tentou se desfazer do entorpecente e que ele obedeceu todo o procedimento de abordagem, salientando, porém, que o réu “estava muito nervoso...tremia muito”. Confirmou que foi quem fez a vistoria no automóvel do réu, no qual não foi percebido compartimento “falso ou secreto”. Pontuou que não foi perguntado ao réu se essa era a primeira vez que ele estava transportando entorpecente, tendo reiterado que, primeiramente, o réu disse que venderia a droga e, posteriormente, informado que a estava transportando para as proximidades da “linha do trem”, na cidade de Presidente Prudente para o fim de quitação de dívida de entorpecente. Asseverou que não foi repassada a informação acerca do local onde o réu havia apontado ter pegado o entorpecente para eventualmente se encontrar quem o havia lá deixado, ressaltando que o acusado não mencionou o local exato onde havia pegado a droga. Elucidou que não foi percebida a presença de rádio HT, mapa dentro do veículo do réu. Consignou que não foi notada a presença de “batedor” acompanhando o veículo do réu. Relatou que o réu em nenhum momento tentou se evadir.

A testemunha de defesa Rosimeire de Oliveira narrou conhecer o réu há quase 30 anos e que já frequentou muito a casa dele, atualmente não mais a frequenta e que, quando frequentou a casa do acusado, não percebeu movimentação típica de tráfico de drogas. Elucidou que o réu mora no bairro “José Rotta”, em Presidente Prudente. Afirmou que não estava presente no momento da prisão do acusado. Informou que nunca ouviu comentário no sentido de que o réu fosse traficante de drogas. Disse fazer cinco meses que havia conversado com a esposa do acusado, a qual afirmou que ele estava com “jeito diferente...mais agressivo” e que ela desconfiava que ele estava fazendo uso de droga - cocaína. Não tem conhecimento se o réu procurou ajuda para se libertar do vício. Consignou que o acusado tem família constituída - esposa e dois filhos, estes menores de idade. Mencionou que quando frequentava a casa do réu, soube que ele trabalhava em uma empresa de bebida - “Funada”, situada na cidade de Presidente Prudente, ressaltando que a esposa do réu lhe disse que atualmente ele estava trabalhando com venda de veículos.

A testemunha de defesa Philipe Gregório mencionou conhecer o réu há aproximadamente três anos, ressaltando que trabalham juntos comprando e revendendo veículos, em parceria, sendo o lucro igualmente dividido. Consignou que divulgam seus trabalhos por redes sociais e que, aproximadamente, ganham em torno de R\$ 2.000,00, por mês. Afirmou que não estava presente no momento da prisão do réu e que nunca ouviu falar que o acusado fosse traficante de drogas. Asseverou que o réu já lhe disse ser usuário de droga - cocaína. Disse que o réu possuía aparelho celular e que o

próprio acusado, por volta de vinte dias antes de ser preso, afirmou que acabou o vendendo "a troco de cocaína". Não soube dizer se o acusado mora em casa própria, esclarecendo que o réu possui uma Palio Weekend, carro popular, ano 2003. Não sabe se o réu chegar a procurar ajuda para largar o vício em drogas. Declarou que o carro possui família constituída - esposa, com quem tem dois filhos e um filho de outro relacionamento, ressaltando que o "acusado ama a família dele". Consignou que a esposa do réu trabalha como manicure. Por fim, informou que já presenciou o réu trabalhar entregando bebidas no bar do pai do declarante.

A testemunha de defesa Marcelo Abreu Magalhães, Delegado de Polícia, declarou se recordar do caso em tela. Esclareceu que na Delegacia o réu informou que era usuário de droga e que iria entregar o entorpecente na cidade de Presidente Prudente, "salvo engano na linha de trem" para pessoas conhecidas dele. Não se recorda exatamente se o réu informou que na época estava com dívida de droga, mas que o acusado estava "temeroso" de sofrer represália. Elucidou que policiais vistoriaram o veículo apreendido. Não se recorda se no veículo foram encontrados rádio HT, celular e considerável numerário em espécie. Asseverou que o réu não era conhecido nos meios policiais de Regente Feijó, ressaltando, porém, haver antecedentes criminais do réu, apesar de não se recordar precisamente. Não se recorda se o réu possuía alguma alcunha, não tendo sido identificado se o réu participava de alguma organização criminoso ou se foi identificado algum usuário que atribuiu ao réu a função de fornecedor de entorpecente. Detalhou o depoente que o réu estava levando a droga para a cidade de Presidente Prudente. Não tem conhecimento se o carro do réu era utilizado para [outros] transportes de drogas. Que se não estiver enganado, a abordagem do veículo do réu se deu em razão da suspensão do automóvel estar elevada ou abaixada, não se recordando se o veículo foi submetido a perícia.

O réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que estava devendo para traficante, salientando ser usuário de cocaína. Que lhe foi feita a proposta para buscar o entorpecente na cidade de Anhumas. Que, então, pegou a droga, sendo isso de manhã/cedo, e que quando estava retornando, na vicinal da cidade de Anhumas, visualizou a Polícia Rodoviária, tendo notado que o policiamento fez o retorno e passou a segui-lo, por três a quatro minutos, e que quando adentrou a Rodovia Raposo Tavares, a guarnição continuou a segui-lo, pareando a viatura com seu veículo e, em seguida, lhe deram sinal de parada, o que obedeceu imediatamente. Que, então, houve a abordagem, tendo sido encontrado o tijolo do entorpecente em sua cintura. Consignou que não sabia que droga que era e que, somente posteriormente, ficou sabendo qual era. Esclareceu que iria deixar a droga próximo à linha férrea. Afirmou que o transporte da droga iria quitar sua dívida - R\$ 800,00. Não quis indicar os destinatários de sua conduta, por ter receio de sofrer represália ou de prejudicar sua família. Confirmou que cometeu um erro e que está arrependido do que fez. Informou que não sabia a natureza e nem a quantidade do entorpecente que teria que transportar e que foi a primeira vez que fez "isso". Declarou possuir há dois...três anos o veículo envolvido nos fatos e que foi ele, depoente, quem mexeu na estrutura do automóvel, porque o veículo era baixo, estava com "pneus altos" a ponto de, ao passar em obstáculo, o pneu pegar na estrutura do veículo e que, então, levou o automóvel ao mecânico, o qual sugeriu a elevação da suspensão. Relatou que seu automóvel vale entre R\$ 10.000,00 e R\$ 12.000,00. Afirmou que pelo trajeto que faria de retorno para a cidade de Presidente Prudente acabaria por passar pela base da Polícia Rodoviária de Presidente Prudente. Disse que, à época, era dependente químico e que procurar ajuda - Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aduziu que informou aos policiais que era dependente químico. Negou que fosse vender o entorpecente. Asseverou que ao ser abordado pelos policiais, esses não o informaram acerca do direito constitucional de permanecer calado e que, mesmo assim, explicou tudo o que estava acontecendo. Negou que estivesse com celular no dia dos fatos, ressaltando que já estava entre quinze a vinte dias sem referido aparelho. Esclareceu que tinha aparelho celular, mas que o entregou para pagamento de dívida. Elucidou que, no momento da prisão, tinha R\$ 112,00. Negou possuir apelido. Mencionou que trabalha, há aproximadamente três anos, com compra e venda de carros e que sua renda mensal varia, frisando que tem

que dividir o lucro com a pessoa com quem trabalha, sendo de aproximadamente R\$ 2.300,00 mensais. Confirmou que divulga seu trabalho em rede social. Ressaltou que seus filhos são menores de idade. Pois bem.

Inicialmente, pontue-se que o fato de os policiais estarem presentes quando da abordagem na situação de flagrância não implica impedimento para a tomada de seus depoimentos em juízo, sob compromisso. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Aliás, falando-se em policiais, civis ou militares, mesmo guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam, prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada (...)" (TJ-SP - Apelação Criminal n. 3001363-88.2013.8.26.0333, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, 10/12/2015).

Os depoimentos prestados pelos policiais gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Prosseguindo, conforme se depreende das provas acostadas aos autos, indubitável que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Os policiais militares, em juízo, foram firmes e uníssonos em aduzirem que, com o réu, na altura da cintura, foi encontrado um tijolo/tablete de crack, tendo ambos os policiais narrado que o réu informou que teria pegado a droga perto de uma placa de sinalização de trânsito, em estrada vicinal de acesso à cidade de Anhumas e que levaria o entorpecente para a cidade de Presidente Prudente e, assim, quitaria dívida de entorpecente (R\$ 800,00) com traficante dessa última cidade, relatos esses, corroborados pelo depoimento de Marcelo Abreu Magalhães, Delegado de Polícia, que confirmou que o acusado estava levando a droga para a cidade de Presidente Prudente.

As testemunhas de defesa Rosimeire e Philipe não presenciaram o momento da prisão do réu.

Por fim, o réu confessou a prática delitiva, tendo afirmado que pegou o entorpecente na cidade de Anhumas e que o levaria até a cidade de Presidente Prudente e, assim, quitaria dívida de R\$ 800,00 que tinha com traficante.

E o auto de exibição e apreensão (fl. 19), as fotografias de fls. 20/21, o auto de constatação preliminar (fls. 26/27) e o laudo pericial de fls. 97/99 confirmam a natureza e a quantidade do entorpecente que o réu trazia com ele/que era por ele transportado - 1,055 Kg de cocaína na forma de crack, acondicionada em 01 tijolo. Não afasta a responsabilidade criminal do acusado o fato de que inicialmente não soubesse a natureza e a quantidade da droga, pois era evidente que sabia que estava transportando ilícito (entorpecente), não se podendo admitir que o réu se beneficie ao se colocar em situação de "cegueira deliberada", sendo, pois, hipótese de aplicação da teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine ou teoria das instruções da avestruz), isto é, de se reconhecer que o réu se colocou deliberadamente em condições de ignorância proposital a fim de incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentar furtar-se à responsabilidade criminal que deve recair sobre ele, o que, frise-se, não vinga.

Nem se cogite, ainda, em inexigibilidade de conduta diversa.

Fato é que, para classificar a conduta de determinado agente como reprovável, é imprescindível que se possa exigir deste indivíduo, naquela situação fática,

conduta diversa, cenário dos autos, porquanto plenamente possível se concluir o caráter ilícito do transporte/trazer consigo a droga, realizado pelo réu, tendo em vista as características de sua “contratação”, ou seja, que não foi forçado a praticar a conduta em análise, mas que a aceitou com a finalidade de, em tese, mais fácil e rapidamente, pôr fim à dívida que disse ter com o traficante. Sobre o tema, lecionam André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves: Para dizer que alguém praticou uma conduta reprovável, é preciso que se possa exigir dessa pessoa, na situação em que ela se encontrava, uma conduta diversa. Reinhard Frank foi pioneiro na sistematização desse critério, inserindo-o dentro da culpabilidade. O autor estabeleceu como premissa fundamental a de que só se pode impor pena ao autor de um injusto (fato típico e antijurídico) quando se demonstrar ter sido seu comportamento reprovável. Para tanto, é necessário que dele se possa exigir conduta diversa, ou seja, que na situação em que o fato foi cometido, seja lícito concluir que o agente possuía uma alternativa válida de conduta. Se, por outro lado, verificar-se que as condições exteriores não lhe davam outra saída senão agir daquela maneira, seu ato não poderá ser tido como censurável. A ausência da censurabilidade acarreta a falta de culpabilidade e, desta forma, isenta-o de pena. Esse raciocínio funda-se no livre-arbítrio, isto é, na tese de que se deve punir alguém quando o ilícito resultou de uma livre opção; sem esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não será justo aplicar a pena criminal (ESTEFAM, A.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado: parte geral. 5 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Outrossim, menos ainda de prosperar a tese de estado de necessidade. É absolutamente inaceitável considerar que circunstâncias de dificuldade financeira sejam aptas a autorizar condutas criminosas, sob pena de desencadear uma alarmante situação de insegurança jurídica e estremecer o convívio social, principalmente em localidades onde há concentração de pobreza.

Ademais, o tráfico de entorpecentes engendra infortúnios à população, de maneira geral, e ao Estado, vez que a distribuição de drogas afeta não só a vida do viciado e o convívio social, causando danos muitas vezes irreversíveis, como também o próprio Estado, em virtude dos prejuízos acarretados à saúde pública, bem penal tutelado pelo tipo.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Tráfico de drogas. 16,07g de cocaína. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. 2. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais, que se mostram coerentes e harmônicos. 3. Quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, apreensão do dinheiro, indicam o intuito de mercancia. Impossibilidade de desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06. 4. Inexigibilidade de conduta diversa. Alegações atinentes às dificuldades financeiras do réu para satisfação das necessidades vitais próprias e de sua família não foram comprovadas pela Defesa, ônus imposto por expressa previsão no artigo 156 do CPP. Situação de dificuldades pelas quais a Defesa alega que o réu passava deve ser resolvida por meios idôneos. 5. Reprimenda reduzida. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11/343/06 na fração máxima de dois terços. Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no mínimo legal. 6. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", tendo em vista a quantidade de pena fixada e o tempo de prisão cautelar. 7. Conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação 0045313-74.2012.8.26.0224; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2014; Data de Registro: 22/01/2015).

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE CONDUTA DIVERSA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...) 4. A existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. E o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré. 5. Não se acolhe a tese da defesa no sentido de aplicação das chamadas "teoria da co-culpabilidade" e da "culpabilidade funcional", teorias modernistas, que se tenta inserir no Direito Penal brasileiro, fundadas no sistema funcionalista do crime, na sua vertente racional-teleológica, também conhecida como "funcionalismo moderado". Tratam-se de teorias extremamente garantistas, que visam mais a beneficiar, e mesmo fomentar, a prática de novos crimes, não impingindo as devidas punições aos agentes criminosos, como forma de repelir novas práticas delitivas. Desta feita, não se pode conferir validade à pobreza, baixa escolaridade ou descaso do Estado para se justificar e permitir a prática de condutas penalmente tipificadas (...) (TJSP; Apelação 0003035-82.2014.8.26.0161; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015).

Destarte, comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como ausentes causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é a medida de rigor.

Passo, pois, a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e artigo 59, do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e quantidade do entorpecente (foi apreendida considerável quantidade de cocaína na forma de crack, haja vista a vasta quantidade de porções que o tijolo/tablete apreendido poderia gerar, o que será considerado na terceira fase da dosimetria da pena para modular a aplicação da causa de diminuição específica prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo penal, ausentes circunstâncias agravantes. Presente, lado outro, a circunstância atenuante referente à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545, STJ). Ocorre que a pena nesta fase da dosimetria não pode atingir patamar abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ), de forma que a mantenho no sobredito quantum (patamar mínimo legal).

Na terceira fase do cálculo penal, ausente qualquer causa de aumento de pena. Ainda nesta fase da dosimetria da pena, presente a minorante descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

O escopo do legislador ao estabelecer o privilégio foi de diferenciar o traficante habitual do neófito, beneficiando o segundo com uma causa especial de diminuição de pena. Bem por isso, para a aplicação do redutor, é necessário que o agente seja primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, exatamente como ocorre no caso em tela.

A condição de "mula", por si só, não é apta a afastar a incidência do benefício, haja vista que, somando-se à primariedade, bons antecedentes e ausência de prova quanto à integração em organização criminosa, não há indicador de que o agente se

dedique a atividades criminosas.

Assim, a qualidade de "mula", per se, não altera a condição de "traficante de primeira viagem", de forma que não justifica o afastamento da causa específica de diminuição de pena por não descaracterizar nenhum dos requisitos subjetivos exigidos pelo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, já decidiram o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o C. Superior Tribunal de Justiça e o Pretório Excelso:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Maconha. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes com o réu, que confessou em Juízo transportá-los em viagem interestadual. Majorante. Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Afastamento. Impossibilidade. Droga que era transportada de São Paulo com destino a Minas Gerais, pouco importando a não transposição da fronteira entre os Estados. Condenação mantida. Penas que comportam pequeno ajuste, para que a básica seja estabelecida no mínimo legal. Manutenção, por outro lado, do mínimo redutor decorrente do "tráfico privilegiado" e da fixação do regime inicial fechado. Parcial provimento do recurso" (TJSP; Apelação 0000747-51.2017.8.26.0099; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).

"PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APRECIACÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ALEGA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA CDO REDUTOR MENCIONADA PELA JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Impõe-se o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto a apelante preenche todos os requisitos estabelecidos em lei, na medida em que é primária, não possui antecedentes maculados, além de não haver provas nos autos de que esta se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Embargos acolhidos" (TJSP; Embargos de Declaração 0000134-62.2016.8.26.0585; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).

Desta feita, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como inexistentes provas no sentido que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, necessária se faz a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao quantum, vislumbro que o redutor deve ser aplicado em sua medida mínima. Isso porque, o réu transportava considerável quantidade de droga, pouco mais de um quilo, de natureza altamente danosa ao organismo (cocaína na forma crack).

Assim, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Sopesando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam grande reprovabilidade da conduta e grave risco social, e considerando a prática de crime gravíssimo (tráfico ilícito de considerável quantidade de cocaína, na forma crack), fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Frise-se que o regime fechado é o mais adequado para satisfazer o caráter preventivo e repressivo da sanção, uma vez que, além de a traficância ser mola propulsora da criminalidade, o réu agiu para contribuir para a distribuição e disseminação de entorpecente altamente devastador pelo país.

Pelo montante de pena fixado, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Também, pela mesma razão, não cumpre os requisitos para a concessão do sursis (art. 77, caput, do CP).

- Da detração:

Por força do § 2º do art. 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, em linha de princípio, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar

a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar novo capítulo na sentença condenatória para a análise de eventual progressão de regime. Entrementes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações legalmente estabelecidas, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito do sentenciado, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização.

Cumpra registrar que a inovação legislativa instituiu uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição o reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência.

Ou seja, para a progressão de regime há uma série de fatores que devem ser computados. E, no presente caso, ainda que tivesse o réu cumprido o requisito objetivo (temporal), a análise de mérito, pela própria natureza e gravidade do delito perpetrado, não prescinde, no entender deste Magistrado, da prévia submissão de análise dos elementos subjetivos.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para CONDENAR o réu OSCAR LIMA DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e praticou crime gravíssimo, qual seja, o tráfico de pouco mais de um quilo de cocaína na forma de crack, o que torna o grau de reprovabilidade da conduta ainda maior.

Assim, a presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o *fumus boni juris* necessário para a manutenção da custódia cautelar do acusado.

Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inaplicável a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória, pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RHC 177 - RJ- 5; Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89 - RT 504/339).

Não bastando, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo, caso queira, recorrer custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado a sentença:

- a) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
- b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º,

do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84.

Decreto o perdimento do veículo apreendido (fl. 19), porquanto utilizado para a prática delitiva, já que inegável que o automóvel do/conduzido pelo acusado, de fato, foi utilizado para o transporte da droga. Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ofício à SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de decretar o perdimento do dinheiro apreendido junto com o acusado, pois não evidenciada a sua origem ilícita e nem a sua utilização para a prática delitiva em tela, porquanto, frise-se, é vasta a prova no sentido de que o acusado trazia consigo/transportava o entorpecente da cidade de Anhumas para a cidade de Presidente Prudente com a finalidade de, entregada a droga no destino final, obter a quitação de dívida existente com traficante. Com o trânsito em julgado, restitua-se ao réu a quantia apreendida (fls. 19 c/c 96).

Custas ex legis.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Regente Feijó, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA